

1500604-87.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e benefícios quanto à pena e ao regime (fls. 319/322).

Por fim, a Defesa do réu Hiago requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e benefícios quanto à pena e ao regime (fls. 336/40).

É o relatório.

Decido.

Não há que se falar em violação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, 1º andar - Centro

CEP: 15010-902 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17)3233-6700 - E-mail: riopreto5cr@tjsp.jus.br

1500604-87.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500604-87.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Henrique Oliveira Mogentale e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Vistos.

HIAGO RENNER SOUZA DOS SANTOS, GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA MOGENTALE e NATHAN TEBOM DOS SANTOS CESÁRIO, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 30 de março de 2022, por volta de 01 hora, na Rua São Jerônimo nº 409, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu Guilherme, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, trazia consigo com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 26,87 gramas de maconha, em uma porção média.

Consta nos autos que no mesmo dia, horário e local, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, os réus Hiago e Nathan, após aquisição de pessoa não identificada, agindo em concurso e divisão de tarefas entre eles, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, tinham em depósito e guardavam, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 1.385,28 gramas de maconha, fracionadas em 08 porções, sendo 01 tijolo e 07 porção menores.

Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 24/26), imagens das drogas apreendidas (fls. 47/52 e 56), laudo de constatação (fls. 65/67), exame químico-toxicológico do entorpecente (fls. 114/116), das balanças, plásticos (fls. 120/122) e facas apreendidas (fls. 123/125) e exame pericial dos telefones celulares apreendidos (fls. 227/248).

Os réus foram notificados (fls. 183, 185 e 187) e apresentaram defesas preliminares (fls. 144/152, 166/168 e 191/192).

A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2022 (fls. 198/200).

O réu foi citado (fls. 250, 252 e 254).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas as testemunhas PM Admilson Donizete Santos Noveli, PM Lairon André Machado Cavassana, Felipe Marcelo Gonçalves, Sidney Toloi Filho e Ramon da Silva Agudo, bem como os réus foram interrogados; homologada a desistência da oitiva da testemunha de defesa Marina Lopes da Silva de Souza. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 309/318).

Em alegações finais a defesa do réu Nathan alegou nulidade por ingresso ilegal no imóvel e no mérito requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e benefícios quanto à pena e ao regime (fls. 300/308).

A defesa do réu Guilherme requereu o reconhecimento da nulidade da confissão informal do réu e por invasão de domicílio. No mérito requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e benefícios quanto à pena e ao regime (fls. 319/322).

Por fim, a Defesa do réu Hiago requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e benefícios quanto à pena e ao regime (fls. 336/40).

É o relatório.

Decido.

Não há que se falar em violação do direito constitucional ao silêncio ou em nulidade da confissão informal.

A priori, saliento que não há, no direito brasileiro, uma regra explícita sobre o chamado "Aviso de Miranda (advertência de Miranda, Miranda warning ou Miranda rights), originado do julgamento Miranda vs. Arizona, da Suprema Corte dos Estados Unidos (384 U.S 436, de 1966); todavia, o art. 5º, LXIII, CF dispõe que: o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Além do mais, serão consideradas ilícitas as provas obtidas a partir de declarações do preso sem prévia e formal advertência quanto ao direito ao silêncio (art. 157, CPP)." (COSTA, Klaus Negri; ARAÚJO, Fábio Roque. Processo Penal didático. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 65-66) Entretanto, para a caracterização da violação do direito ao silêncio e a não autoincriminação, é necessário que haja interrogatório "forçado", em que o investigado é obrigado a falar, ou algum tipo de ambiente intimidatório que diminua seu direito de não incriminação, o que não ocorreu nos autos.

Saliento que há informação de que policiais advertiram o réu do seu direito de permanecer em silêncio, não sendo produzida prova a embasar a nulidade alegada.

Ademais, para o reconhecimento da nulidade em razão da falta de informação acerca do direito de permanecer em silêncio demanda a demonstração de prejuízo concreto, o que não é o caso do presente feito, já que a conclusão da conduta ilícita do réu é extraída de outros elementos de prova

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DE

QUALIFICADORA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. ADVERTÊNCIA SOBRE DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DENEGACÃO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Absolvição quanto ao crime do art. 311 do CP por ausência probatória. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, tendo em vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano. 2. O afastamento da qualificadora concernente ao crime de estelionato, além de não encontrar respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, demandaria necessariamente o revolvimento das provas dos autos, o que não se admite na via do estreito do writ. Precedentes. 3. Infringência ao princípio nemo tenetur se detegere. A jurisprudência dessa Corte Superior consolidou-se no sentido de que a falta de informação acerca do direito de permanecer em silêncio constitui nulidade relativa, que demanda a demonstração de prejuízo concreto para ser reconhecida, o que não é o caso do presente feito. Precedentes. 4. Tese de nulidade aventada somente em sede de embargos, sem qualquer menção ao pleito em momentos processuais antecedentes – defesa prévia, instrução, alegações finais e apelação –, restando obstada pela operação do instituto da preclusão. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido., ressaltei (STJ, AgRg no Habeas Corpus nº 472.683 – SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/02/2020)

Dessa forma, não há que se falar em nulidade.

Também descabida a alegação de nulidade por invasão do imóvel sem a devida autorização judicial. Isso porque os policiais agiram respaldados por elementos concretos, pois abordaram Guilherme portando drogas em situação de tráfico, sendo que ele afirmou que na residência havia mais entorpecente. Logo, havia elementos concretos suficientes a indicar fundada suspeita da ocorrência flagrantial no interior do imóvel.

Nesse sentido, há tese fixada pelo STF:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. STF. Plenário. RE 603616/R0, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral) (Info 806).

Assim, o ingresso regular da polícia no domicílio em caso de flagrante delito é válido diante da presença de fundadas razões (justa causa) que sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência, afastando-se a tese defensiva (tese discutida no julgado paradigma - STJ. 6ª Turma. REsp 1.574.681-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 20/4/2017, Info 606).

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, notadamente auto de exibição e apreensão (fls. 24/26), imagens das drogas apreendidas (fls. 47/52 e 56), laudo de constatação (fls. 65/67), exame químico-toxicológico do entorpecente (fls. 114/116), das balanças, plásticos (fls. 120/122) e facas apreendidas (fls. 123/125), exame pericial dos telefones celulares apreendidos (fls. 227/248), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O corréu Hiago, na fase policial (fls. 06), disse que estava confraternizando com os amigos Natan e Guilherme na casa de Marina, mulher de Natan, quando foram surpreendidos por policiais militares que entraram na residência e pediram para deitarem no chão com as mãos para trás. Afirmou que estavam tomando cerveja e fumando maconha porque é dependente químico e faz uso constante de maconha. Alegou que não sabe nada sobre a droga encontrada na casa de Marina, pois o tempo todo esteve deitado no chão. Alegou que nunca praticou o tráfico de drogas.

Em juízo reiterou a versão prestada em solo policial. Quanto aos diálogos constantes no laudo de fls. 227/248, disse não se recordar.

O corréu Guilherme, na fase policial (fls. 07), disse que estava na casa de Marina,

namorada de Natan, com outros amigos, tomando cerveja e fumando maconha, quando, subitamente, policiais militares entraram a residência e disseram para que os três ficassem deitados no chão de bruços; posteriormente os policiais disseram que encontraram drogas na casa. Relatou que faz uso de maconha, pois é dependente químico e nunca cometeu o crime de tráfico de drogas. Não sabe dizer sobre a droga encontrada e se realmente foi encontrada na casa, pois ficou o tempo todo deitado no chão com o rosto virado para o chão.

Em juízo, reiterou a versão prestada em solo policial, quanto aos diálogos constantes no laudo de fls. 227/248, alegou que intermediava drogas, maconha, mas não recebia dinheiro por isso, mas droga para seu uso.

O corréu Nathan, na fase policial (fls. 09), disse que estava na casa de sua namorada Marina com dois amigos, Guilherme e Hiago; fumavam maconha e tomavam cerveja quando foram surpreendidos por policiais militares que entraram a residência e determinaram que os três ficassem deitados no chão de bruços. Depois de um tempo, os policiais disseram que haviam encontrado drogas na casa. Afirmou fazer uso de maconha, pois é dependente químico e a droga encontrada na casa de Marina era de sua propriedade, afirmando que iria fracionar e fazer a venda. Disse que pagou R\$ 1.300,00 pela droga e a revenderia para levantar um dinheiro.

Em juízo, disse que estava na casa de Marina, sua namorada, tomando cerveja com os corréus seus amigos, quando policiais invadiram o imóvel e perguntaram a Marina se havia drogas no local, sendo por ela dito que não. Na sequência, perguntaram a Marina se alguém morava com ela no local, ela disse que ele morava; então os policiais o levaram para um canto e começaram a agredi-lo e perguntar onde estava a droga. Disse que a pegou a droga que estava na lavanderia e entregou aos policiais. Alegou que a droga apreendida lhe pertencia, que pagou cerca de R\$ 1.000,00, e a venderia por R\$ 2.000,00. Acrescentou que os corréus e Marina não sabiam da existência da droga, alegando que havia picado apenas cinco porções para seu uso e o restante venderia. Quanto aos diálogos constantes no laudo de fls. 227/248, disse não se recordar.

Os policiais militares Admilson e Lairon, na fase policial (fls. 03 e 04), bem como em juízo, narraram que realizavam patrulhamento pelo local dos fatos junto à equipe BAEP 62 quando avistaram um indivíduo conversando com um rapaz que estava em uma motocicleta; contudo, ao perceberem a viatura, o condutor da motocicleta se evadiu do local. Abordaram o rapaz, que foi identificado como sendo o réu Guilherme, o qual tentou entrar em uma casa próxima, porém antes que ele entrasse na residência, foi solicitado a parada e ele foi abordado; em busca pessoal, encontraram com ele uma porção média de maconha, um celular Motorola preto e R\$ 34,00. Afirmaram que Guilherme disse que venderia o entorpecente para o condutor da motocicleta. Ao ser indagado sobre a casa que havia tentado entrar, Guilherme respondeu que a casa era de uns amigos e que no local havia mais drogas. Narraram que foram até a residência e lá encontraram outro rapaz, identificado como Hiago, que no momento tentava esconder quatro porções de maconha em meio aos alimentos, dentro de um armário na cozinha. Em busca pessoal, com Hiago encontraram R\$ 50,00 e um celular de marca Samsung azul; Hiago disse estar ali apenas para tomar uma cerveja. Disseram que do lado de fora da casa, em uma lavanderia, abordaram o réu Natan, que tentava esconder duas porções grandes de maconha, uma balança de precisão, sendo um tijolo e a outra porção metade de um tijolo; em busca pessoal, também localizaram com Natan R\$ 50,00 e dois celulares, um Iphone preto e um Samsung azul com ele. Natan disse ter comprado a droga no Bairro João Paulo II e pagado o valor de R\$ 1.100,00 e que iria fracionar e vender a droga, dizendo que auferiria R\$ 2.000,00 com a venda, confessando a prática do crime de tráfico de drogas. Informaram que no mesmo local havia uma mulher que aparentemente tomava banho, tendo se identificado como Marina, moradora e responsável pela residência; no quarto dela, em um guarda-roupas, localizaram uma porção de maconha, uma balança de precisão e três facas com resquícios de maconha; ao ser indagada disse que a droga era para seu uso pessoal e que a balança de precisão era para pesar marmitas.

Em juízo, o policial Admilson reiterou a versão prestada em solo policial, acrescentando que a porção de droga encontrada com Guilherme, quando ele estava na via pública, era idêntica à droga encontrada dentro da residência. Afirmou que

estava presente em todas as entrevistas feitas aos réus e que eles tiveram oportunidade de permanecerem em silêncio; disse que não filmou tal conduta porque a região ainda não dispõe de sistema de câmeras para realizar a gravação da abordagem policial.

Em juízo, o policial Lairon reiterou a versão prestada em solo policial, acrescentando que não se recorda se foi ele quem revistou Guilherme. Disse que viu Guilherme entregando alguma coisa ao motociclista e, posteriormente, o réu Guilherme afirmou que entregaria maconha ao motociclista. Narrou que entrou no imóvel com a autorização de Guilherme, após ele afirmar que havia droga na residência.

A testemunha de defesa Felipe Marcelo Goncalves, ouvida somente em juízo, afirmou que é amigo do réu Guilherme; disse que trabalham juntos, que o réu é responsável no trabalho, tem residência fixa e não sabe se o réu faz uso de droga, ele nunca chegou alterado para trabalhar.

A testemunha de defesa Sidney Toloi Filho, cunhado do réu Guilherme, ouvida somente em juízo, afirmou que o réu é trabalhador, tem residência fixa, reside com a mãe. Nunca soube que o réu faz uso de entorpecente; é boa pessoa, nunca deu trabalho aos seus familiares.

A testemunha de defesa Ramon da Silva Agudo, ouvida somente em juízo, afirmou que é amigo do réu Nathan, ele é seu funcionário na barbearia que é de sua propriedade. Pois bem.

Conforme exposto, não resta dúvida de que os réus praticavam o tráfico de drogas. Nesta esteira, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram o réu GUILHERME conversando com um rapaz que conduzia uma motocicleta. Ao notarem a presença dos policiais, o condutor arrancou com o veículo, evadindo-se do local; Guilherme foi abordado tentando entrar na residência situada na Rua São Jerônimo nº 409.

Em busca pessoal, foi localizada uma porção média de maconha em uma bolsa preta trazida por Guilherme, além de um aparelho celular e a quantia de R\$34,00.

Questionado, Guilherme admitiu que venderia a droga ao condutor da motocicleta e que o local onde estava entrando era residência de amigos e havia mais drogas.

Em buscas no imóvel, os policiais se depararam com HIAGO, o qual estava tentando esconder quatro porções de maconha dentro de um armário da cozinha, em meio aos alimentos. Com Hiago, foram encontrados a quantia de R\$50,00 e um aparelho celular. Do lado de fora do imóvel, na lavanderia, os policiais abordaram NATHAN, que tentava esconder duas porções grandes de maconha, sendo um tijolo e meio do entorpecente, e uma balança de precisão. Com o NATHAN foram localizados dois aparelhos celulares e a quantia de R\$50,00. Questionado, NATHAN afirmou ter comprado a droga no bairro João Paulo II pela quantia de R\$1.100,00 e que pretendia vendê-la por R\$2.000,00.

No interior da residência, os policiais abordaram Marina Lopes da Silva de Souza, proprietária do imóvel, e localizaram uma porção de maconha em seu guarda-roupas, além de uma balança de precisão e três facas com resquícios de droga. Questionada, a moradora informou que a droga era para seu consumo pessoal.

Comprovado que as substâncias apreendidas se tratava de maconha, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 24/26), imagens das drogas apreendidas (fls. 47/52 e 56), laudo de constatação (fls. 65/67), exame químico-toxicológico do entorpecente (fls. 114/116), das balanças, plásticos (fls. 120/122) e facas apreendidas (fls. 123/125).

Tais fatos e circunstâncias dão a certeza de que os réus estavam praticando o tráfico de drogas; prova disso são circunstâncias da localização da droga e quantidade de entorpecente apreendido.

Ademais, exame pericial dos telefones celulares apreendidos (fls. 227/248) comprova o envolvimento do trio com a traficância, uma vez que há conversas entre eles tratando de venda de entorpecente.

Nesse sentido, entre outros, há diálogo entre Nathan e Guilherme, eles conversam sobre a venda de 10 quilos de droga ("fechou confirma aqui com os caras que um qué é dois, outro qué três, outro qué cinco você entendeu té dar os 10 entendeu. Aí eu já lá para tarde os cara falou que vai dar a certeza de quantos quilos vai

entendeu?", fls. 236); em outro diálogo entre o réu Nathan e "Renner" (réu Hiago), ambos comercializam 20 quilos ("aí tem um mano aqui que quer 20 kg dessa comercial aí mano vai ter que fazer um precinho mais da hora aí para nós né?", fls. 237). O conteúdo das conversas não deixa qualquer dúvida sobre o conluio dos réus para o tráfico de drogas, vez que os três falam abertamente sobre venda e compra de entorpecentes.

Ademais, aliado às declarações dos policiais, tem-se a confissão de Nathan, que narrou que armazenava droga e pretendida dividi-la em porções para venda.

Assim, a negativa dos réus em juízo, quanto à autoria de Guilherme e Hiago, pueril, não convence, até porque não apontaram qualquer motivo razoável para que os policiais os incriminassem leviana e gratuitamente.

Os policiais são funcionários públicos têm responsabilidade funcional com seus superiores, com a Justiça, com a sociedade e com suas famílias. Não se crê que policiais saiam em diligências portando drogas para intrujar em pessoa que sequer conhece, sob o sério risco de responsabilização pessoal e funcional, de perder seu trabalho, sem qualquer motivo sério e razoável.

Ademais, o laudo dos aparelhos celulares comprova, isente de dúvida, a autoria dos três réus na prática do tráfico de drogas.

Desta forma, comprovada a autoria e materialidade, de rigor a condenação do réu.

Passo a dosar a pena:

Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que os réus não possui antecedentes criminais relevantes (fls. 84/85, 89, 292/295); entretanto, considerando-se as circunstâncias estabelecidas no artigo 42 da Lei 11343/06, há que se considerar que os réus comercializavam elevada quantidade de drogas, uma vez que além do total de maconha apreendida (cerca de 1.400 gramas), fato é que os três vinham transacionando muita droga, como se pode extrair dos trechos das conversas constantes nos aparelhos apreendidos deles.

Nesse sentido, em diálogo entre Nathan e Guilherme, eles conversam sobre a venda de 10 quilos de droga ("fechou confirma aqui com os caras que um que é dois, outro que três, outro que cinco você entendeu té dar os 10 entendeu. Aí eu já lá para tarde os cara falou que vai dar a certeza de quantos quilos vai entendeu?", fls. 236); em outro diálogo entre o réu Nathan e "Renner" (réu Hiago), ambos comercializam 20 quilos ("aí tem um mano aqui que quer 20 kg dessa comercial aí mano vai ter que fazer um precinho mais da hora aí para nós né?", fls. 237).

Tal circunstância que traz a necessidade de reprimenda penal mais severa, pois elevada quantidade de droga apreendida e transacionada pelos réus poderia gerar graves danos à saúde pública, já que atingiria centenas de jovens, causando consequências devastadoras a inúmeras famílias. Assim, a pena-base é fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal.

Na segunda fase incide a circunstância atenuante da confissão extrajudicial para o corréu Nathan. Assim, para o corréu Nathan a pena retorna ao mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, enquanto para os corréus Guilherme e Hiago permanece em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal.

Na terceira fase não é o caso de se conceder o benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Em atenção ao referido dispositivo legal, para a concessão do benefício é imprescindível examinar a presença, cumulativa, de todos os requisitos previstos no citado §4º, quais sejam primariedade, bons antecedentes e a circunstância do agente não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Nos presentes autos, restou demonstrado que os réus se dedicavam à atividade criminosa, porquanto além da grande quantidade de drogas, os diálogos captados entre os réus demonstram, a saciedade, que se dedicavam habitualmente a prática criminosa, não se tratando do pequeno traficante eventual ao qual a Lei pretende beneficiar.

Nesse sentido:

Com efeito, ante a necessidade de individualização da pena criminal e sua aplicação de modo proporcional, é natural que o redutor previsto no § 4º do aludido artigo 33 fique reservado às situações de menor ofensividade, como são aquelas em que se verifica que o agente comercializa drogas menos “pesadas”, em pequena quantidade, apenas para sustentar o próprio vício ou de modo eventual, atuando de modo pouco incisivo na emancipação da toxicomania, o que não se vislumbra no caso em apreço (TJ/SP, Apelação Criminal 0001408-08.2017.8.26.0576, rel. Des. Dr. Otávio Rocha, julgado em 24/07/2019).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. AFASTAR CARÁTER HEDIONDO. PLEITO PREJUDICADO. DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Concluído pelas instâncias antecedentes, com fulcro nos elementos constantes dos autos e no fato de registrar atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento – para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 4. Embora o agente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento das sanções impostas, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza de entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 6. Fica prejudicado o pleito de afastamento do caráter hediondo do delito, pelo não reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. 7. Noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando diante do desconto do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente. 8. Agravo regimental não provido. (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 02/06/2020), ressaltei.

Saliento que não caracteriza bis in idem a valoração da quantidade de droga nas duas fases da dosagem da pena, pois além de haver fundamento legal para a consideração de tal circunstância em ambas as fases (artigo 42 e 33, §4º, ambos da Lei de Drogas), também possuem finalidades distintas. Nesse sentido:

Consigne-se, neste ponto, que não há que se falar que a dupla consideração da quantidade da substância configuraria bis in idem, pois a valoração dessa circunstância nas duas fases da dosimetria encontra fundamento legal e tem finalidades diversas. Na primeira fase da dosimetria da pena, a quantidade dos entorpecentes é considerada para fim de majoração da pena-base e, na terceira fase, eventualmente, para a não aplicação, ou para a modulação, da causa especial de diminuição da pena, cujo objetivo é beneficiar o traficante pequeno e eventual (TJSP, Apelação Criminal nº 0000849-51.2017.8.26.0559, Rel. Luís Augusto de Sampaio Arruda, julgado em 27/06/2019).

À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão

das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima expostas, que demonstram a necessidade de reprimenda penal mais severa, uma vez que a elevada quantidade de droga transacionada e apreendida traz severas consequências negativas à sociedade (note-se que 0,5 gramas de maconha é suficiente para a confecção de um cigarro de maconha, como se tem conhecimento através de leituras de acórdãos e dizeres de testemunhas e usuários a este Juízo), sem olvidar a reincidência do corréu Luís Fernando, nos termos dos artigos 33 e 59 do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, CP notadamente em face da quantidade de pena aplicada e presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, ainda, pela inconciliabilidade com a determinação de cumprimento inicial da pena em regime fechado, sem olvidar a quantidade de pena aplicada.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR HIAGO RENNER SOUZA DOS SANTOS e GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA MOGENTALE às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal e NATHAN TEBOM DOS SANTOS CESÁRIO às penas de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, todos em regime inicial fechado, como incursos no artigo 33, caput, ambos da Lei 11.343/06.

Presos cautelarmente, não poderão recorrer em liberdade, uma vez que a prisão cautelar permanece necessária para a garantia da Ordem Pública e da aplicação da Lei Penal, sendo insuficientes as demais cautelares trazidas pela Lei n. 12.403/11. Quanto ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, impossível a “progressão de regime” neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guias para execução, oportunamente.

Recomendem-se na prisão em que se encontra.

Fica decretada a perda do dinheiro e celulares apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Determino a destruição das balanças, facas e rolos de papel apreendidos.

Condeno os réus nas custas processuais (100 UFESPS), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C..

São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO-REGISTRO/PUBLICAÇÃO.

Certifico e dou fé que, nesta data, os autos foram recebidos com a presente sentença, a qual foi tornada pública, em cartório.

São José do Rio Preto \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

O(A)